

1500242-54.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... que buscou a droga com o pessoal do tráfico, levou para a sua casa e fez as fotos o vídeo. Declarou que então confirmada a negociação, então por volta das 15 horas acompanhado de dois indivíduos do tráfico, que não sabe dizer nome, qualificação ou onde possam ser localizados, pois teme por sua vida e de seus familiares, foram até RUBEM, que costuma fazer carretos com o seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500242-54.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500242-54.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030758/2022 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 22789834 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 6/22/301 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 2030758 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIONE DE PAULA ROCHA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal em face de FRANCIONE DE PAULA ROCHA, de RUBEM ALOÍSIO DOS SANTOS e de RAFAEL NIVALDO DA SILVA, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2022, às 21h30, na Rua José de Oliveira, nº 186, bairro Batistini, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, os réus, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 144 invólucros plásticos, do tipo "tijolo", de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, com peso líquido aproximado de 83,6 quilogramas.

Notificados (fls. 367, 370 e 373), os réus apresentaram defesa prévia (fls. 152/157, 159/161 e 163/165).

Recebeu-se, então, a denúncia (fls. 374/378), citando-se os réus (fls. 423, 425 e 426).

No curso da instrução, tomaram-se as declarações de duas testemunhas, interrogando-se os réus ao final (fls. 436/438).

As partes, então, debateram a causa.

O ilustrado representante do Ministério Público, convencendo-se de que os fatos na denúncia ficaram parcialmente demonstrados, pugnou pela condenação somente de Francione e de Rafael (fls. 436/438).

O douto Defensor, por sua vez, postulou a improcedência da presente ação penal quanto a Francione e Rubem, argumentando, em suma, insuficiência probatória. No tocante a Rafael, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado e, em caso de condenação de Francione, requereu idêntica benesse (fls. 451/458).

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

A pretensão punitiva, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão carreado a fls. 56/58, bem como pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 71/73 e 194/196) estes dois últimos a comprovar a característica entorpecente das substâncias apreendida

A autoria delitiva, por seu turno, exsurge dos autos incontestável.

O réu Rafael, na fase policial (fls. 20/21), asseverou que "... não trabalha registrado, que vive de bicos diversos. Declarou que mantém um relacionamento amoroso com FRANCIONE DE PAULA ROCHA a 8 (oito) anos, tendo com ela duas filhas e que conhece RUBEM ALOISIO DOS SANTOS da rua onde FRANCIONE mora. Declarou que nesta data fora chamado por pessoas do tráfico para fazer a intermediação da venda de uma grande quantidade de drogas e precisaria entregar ela na cidade São Bernardo do Campo, o que foi aceito. Declarou que ligou para a sua namorada FRANCIONE e mandou que a mesma buscasse uma amostra da droga (um tablete) e fizesse fotos e um vídeo para mostrar a qualidade da droga, o que foi feito por ela, que buscou a droga com o pessoal do tráfico, levou para a sua casa e fez as fotos o vídeo. Declarou que então confirmada a negociação, então por volta das 15 horas acompanhado de dois indivíduos do tráfico, que não sabe dizer nome, qualificação ou onde possam ser localizados, pois teme por sua vida e de seus familiares, foram até RUBEM, que costuma fazer carretos com o seu carro, ele estava trabalhando em uma obra, então saiu na rua e combinou com ele um carreto, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) sem falar o que exatamente seria transportado, pegando a chave do veículo HAFEI/TOWNER de placas CHP-2050, para que fosse carregado. Declarou que então os indivíduos saíram com o carro de RUBEM, retornando depois e deixando o veículo com ele. Declarou que foi até a casa de FRANCIONE e pediu que a mesma acompanhasse RUBEM no transporte da droga, pois um veículo com mulher e criança é mais difícil de ser abordado, o que foi aceito por ela. Declarou que por volta das 17 horas passou para FRANCIONE o endereço de onde haveria a negociação e então ela acionou RUBEM e saíram para estar no ponto de encontro por volta das 18 horas. Declarou que foi até o ponto de encontro com o seu veículo FIAT/PALIO de placas CY0-0323, para

finalizar a negociação e receber os valores acordados, sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no qual ficaria com R\$ 3.000,00 (três mil reais). Declarou que chegando no local fez contato com o comprador e pegou uma amostra para ele ver, quando então perceberam a aproximação da polícia e como estava no local a sua namorada e filha não correu, sendo então abordado, enquanto que o comprador conseguiu fugir. Declarou que após a abordagem e o encontro da droga, foram todos trazidos até esta delegacia. Declarou que não falou abertamente para RUBEM que o transporte seria de drogas, mas que o mesmo deve ter desconfiado, ainda assim aceitou fazer o frete, mas foi a sua única participação, Declarou que FRANCIONE só foi acompanhar RUBEM porque ele pediu, que ela não tem envolvimento com o tráfico. Declarou que não possui passagem, mas que a algum tempo mexe com isso. Declarou que usa o telefone de FRANCIONE de vez em quando e que as fotos ali encontradas são suas e não dela, que ela sempre foi contra mexer com isso, mas que o ajuda por amor, para ajudar a família. Declarou que o veículo FIAT/PALIO é seu, mas que está em nome da sua genitora. Por fim declarou que apenas intermedia as negociações das drogas, mas que não tem acesso a fonte das mesmas".

Em juízo (fls. 436/438), Rafael, em linhas gerais, manteve o primitivo relato, mas procurou amenizar a responsabilidade penal dos corréus. Esclareceu que vive em união estável com a ré Francione e que o corréu Rubem é vizinho de ambos. Divergiu ao dizer que quem contratou os serviços de Rubem foi o proprietário da droga. Asseverou Rafael que, no dia dos fatos, ligou para Rubem e lhe afirmou que uma mulher teria que acompanhá-lo, indicando a ré. Mencionou que o dono das drogas é que tratou o valor do frete com Rubem, não mencionando que eram drogas. Asseverou que, no trajeto para o local do encontro, encontrou Rubem, que já estava com o carro carregado. Divergiu Rafael ao dizer que não sabia o valor da negociação dos entorpecentes. Sustentou que não chegou a olhar os entorpecentes com o comprador, pois este, quando notou uma movimentação estranha no local, fugiu. Disse que, na ocasião, somente se encontravam na parte traseira do veículo ele, o réu Rafael, e o comprador. Negou ter realizado intermediações anteriormente. Sustentou que as fotos e vídeos encontrados no aparelho celular de Francione se referiam somente às drogas apreendidas.

Já a ré Francione, na fase inquisitiva (fls. 15/16), relatou que "... conhece RUBEM ALOISIO DOS SANTOS, que reside na mesma rua que a sua, duas casas de diferença da sua e que mantém um relacionamento amoroso com RAFAEL NIVALDO DA SILVA a 8 (oito) anos, tendo inclusive duas filhas com o mesmo, sendo que uma dessas crianças (de 2,5 anos) trazia consigo no momento da abordagem. Relatou que nesta data, por volta das 14 horas, RAFAEL ligou para a mesma e solicitou que fizesse fotos e vídeo da amostra da droga (maconha) que se encontrava embaixo da pia de uma casa do fundo de sua casa, onde não mora ninguém, que então foi até a referida casa, pegou o tablete de maconha e levou até a sua própria casa o fez as fotos e o vídeo que estão no seu aparelho celular. Declarou que por volta das 18 horas, RAFAEL foi até a sua casa e disse que RUBEM (seu vizinho) faria um carreto para o mesmo e era para a indiciada ir junto no veículo dele (HAFEI/TOWNER de placas CHP-2050) porque tendo uma mulher e criança não seriam abordados e além disso, como ainda amamenta onde vai costuma levar a criança. Relatou que então se trocou e ao sair RUBEM já a esperava na frente da casa, então entrou no veículo e saíram sentido ESTRADA GALVÃO BUENO, nº 9041, BATISTINI, SÃO BERNARDO DO CAMPO, endereço passado por RAFAEL. Declarou que chegando no endereço passado por RAFAEL, havia um rapaz desconhecido esperando, que logo que chegaram avisou que não era ali o local de descarregar, pouco depois RAFAEL chegou no local e passou a conversar com esse indivíduo desconhecido. Declarou que depois de um tempo RAFAEL saiu e o indivíduo indicou que deveriam descarregar em outro lugar ali próximo, explicando para RUBEM como chegar no local. Declarou que ao chegar no local indicado, RAFAEL já se encontrava pelo local, então RUBEM parou de frente para o veículo do mesmo, então RAFAEL desembarcou e veio ao encontro de RUBEM e ficaram conversando até que chegaram policiais fazendo a abordagem nos mesmos o quando abriram a porta de trás encontraram vários tijolos de drogas, então deram voz de prisão para RAFAEL e RUBEM e mandaram que a

investigada ficasse de canto com a criança. Declarou que então foram todos trazidos até esta delegacia, onde então pode ver a quantidade de droga que tinha no veículo em que estava. Declarou que nestes 8 (oito) anos que está com RAFAEL, o mesmo nunca trabalhou, declarando para a mesma que sobrevive da renda de aluguéis de imóveis da família. Declarou que RUBEM trabalha como pedreiro e que o viu trabalhando durante o dia, antes de RAFAEL contratar o mesmo para fazer o frete. Declarou que o veículo FIAT/PALIO de placas CY0-0323 pertence a RAFAEL e a HAFEI/TOWNER pertence a RUBEM. Declarou que não sabia que estava transportando aquele tanto de drogas. Declarou que sempre soube que RAFAEL tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Declarou que não sabe se RAFAEL pegou a amostra que deixou novamente na casa, porém olhando as drogas apreendidas nesta delegacia alega que são exatamente iguais ao tablete de droga no qual teve acesso. Declarou que autorizou formalmente os policiais a terem acesso ao conteúdo do seu aparelho celular e que quando da localização das fotos e do vídeo percebeu que esqueceu de apagar, então assumiu que foi a mesma quem fez o vídeo, sendo então informada de que estava presa pelo crime de tráfico de drogas. (...)."

Na fase judicial (fls. 436/438), Francione também procurou amenizar a própria responsabilidade e a do corréu Rubem. Sustentou que Rafael havia deixado com ela o celular dele. Posteriormente, Rafael lhe ligou, pedindo que ela tirasse fotos das drogas, que estavam em uma residência nas proximidades, na rua de cima. Logo depois, Rafael ligou e disse que Rubens iria fazer um carreto. Na ocasião, Rafael pediu que a ré acompanhasse Rubem, pois este é idoso e possuiria dificuldade para acompanhar o "GPS". Rafael, então, esclareceu que drogas seriam transportadas. Quando ela e Rubem chegaram no local, lá havia um rapaz. Logo depois, chegou Rafael com outro carro. Rubem, então, desceu e conversou rapidamente com Rafael, que não chegou a abrir o porta-malas onde estavam os narcóticos. Salientou que Rubem havia dito que iria realizar somente um carreto, não fazendo menção a drogas. Negou que Rafael tivesse envolvimento com drogas. Esclareceu a ré que, na delegacia, atendendo a pedido do delegado de polícia, desbloqueou a senha do celular de Rafael e entregou o bem à referida autoridade. Por fim, mencionou saber que havia uma foto e um vídeo no celular, mas não quis apagá-los.

O réu Rubem, por sua vez, na fase extrajudicial (fls. 18/19), declarou que "... é pedreiro e que nesta data estava trabalhando em uma obra na mesma rua da sua casa quando por volta das 16 horas um conhecido de nome RAFAEL (RAFAEL NIVALDO DA SILVA) o chamou e perguntou se estava fazendo carreto, então o indiciado explicou que faz, porém somente após o final do seu expediente como pedreiro, então RAFAEL falou que um indivíduo de vulgo 'BRANCO' iria procurá-lo para fazer um carreto hoje ainda. Declarou que por volta das 16h30min, o tal indivíduo de vulgo 'BRANCO' o procurou e perguntou se a HAFEI/TOWNER: de placas CHP-2050 era sua e falou que precisava fazer um frete para Taboão, quanto que seria cobrado, então o indiciado cobrou o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), o que foi aceito por 'BRANCO'. Declarou que então 'BRANCO' quis carregar o veículo naquele momento e o indiciado falou que poderia carregá-lo, pois estava aberto alguns metros mais à frente, para que abaixasse o parachoque que a porta abriria, sem olhar o que estava sendo carregado no seu veículo. Declarou que com o veículo carregado RAFAEL falou ao mesmo que iria uma menina junto, mas que não sabia quem era, que ela teria o endereço da entrega. Declarou por volta das 19 horas saiu da obra, tomou um café em casa e entrou no seu veículo, quando então FRANCIONE DE PAULA ROCHA deu sinal com a mão, veio até ele e disse que ela iria acompanhá-lo. Declarou que então FRANCIONE entrou no carro com a sua filha no colo e mostrou o endereço para onde deveriam ir. Declarou que seguindo a orientação de FRANCIONE foram para a cidade de São Bernardo do Campo e pararam no local indicado por ela, quando o tal 'BRANCO' apareceu e disse para que esperasse um pouco para descarregar. Declarou que ficaram alguns minutos parados no local até chegada do RAFAEL, então ele foi até o 'BRANCO' e ficaram conversando, depois RAFAEL foi até a traseira do seu veículo e pegou um tablete de drogas. Declarou que neste momento percebeu que estava transportando drogas, que estava no lugar errado na hora errada, então o tal 'BRANCO' mandou que subisse a rua e ficou com o carro

de frente para o carro do RAFAEL, momento em que viu a viatura e os policiais já efetuando a abordagem deles e quando viram a droga já falaram que estavam todos presos e trouxeram todo mundo para a Delegacia. Declarou que conhece FRANCIONE, pois é sua vizinha e RAFAEL que é quase marido de FRANCIONE. Declarou que após mandar subir a ruas tal 'BRANCO' sumiu, não sabendo dizer onde ele estava no momento da abordagem. Declarou que não conhece o tal 'BRANCO', que ele apareceu por indicação do RAFAEL, que não conhece, não sabe o seu nome ou outros dados o que não sabe onde ele possa ser localizado. Declarou que sabia que RAFAEL era usuário de drogas, mas não que estava envolvido com o tráfico. Declarou que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, que apenas fez um carreto. Declarou que ao observar a quantidade de drogas na delegacia, ficou inconformado como não viu isso tudo no interior do seu veículo, que confiou em RAFAEL".

Sob o crivo do contraditório (fls. 436/438), Rubem, porém, procurou isentar-se de qualquer responsabilidade penal. Sustentou que, na verdade, "Branco" não chegou a aproximar-se do veículo onde estavam as drogas. Negou que Rafael tivesse ido para a traseira de tal automóvel, pois policiais chegaram repentinamente no local e já o abordaram. Negou Rubem que Rafael fosse usuário de drogas. Alegou que não chegou a perguntar o que iria transportar e que não foi conferir o que fora colocado no porta-malas do veículo que iria dirigir.

Não foi bem sucedida, contudo, a tentativa dos corréus Francione e Rubem de afastar, em juízo, a responsabilidade penal que sobre eles pesa.

Por outro lado, nem tudo o que o réu Rafael relatou pode ser tido como verdadeiro.

O policial civil Eder Donizeti Rosa, na fase inquisitiva (fls. 09), mencionou que, no dia dos fatos, ele e seu colega de profissão "...obtiveram a informação nesta data haveria a negociação de vultosa quantidade de drogas para distribuição na região do ABCD e que o ponto de negociação seria a Rua José de Oliveira, no bairro Batistini, na cidade de São Bernardo do Campo/SP e que para o transporte da droga seria utilizado o veículo HAFEI/TOWNER de placas CHP-2050, então no horário informado diligenciaram até o ponto de negociação, onde permaneceram em campana para verificar a veracidade da informação. Relatou que permaneceram no local até verificar a chegada do veículo FIAT/PALIO de placas CYO-0323, ocupado por um indivíduo, que estacionou e minutos depois o veículo da informação (HAFEI/TOWNER de placas CHP-2050), também chegou e estacionou de frente com o primeiro. Relatou que os condutores desceram e ficaram conversando por mais alguns minutos até a chegada a pé de um indivíduo, que após conversas foram para a parte de trás da TOWNER e então decidiram por abordá-los. Relatou que com a aproximação da equipe, o indivíduo que chegou a pé percebeu e correu, enquanto que a equipe focou em abordar os condutores dos veículos, não sendo possível evitar a fuga do primeiro. Relatou que efetuada a abordagem, o condutor do FIAT/PALIO foi identificado como sendo RAFAEL NIVALDO DA SILVA e no HAFEI/TOWNER estavam RUBEM ALOISIO DOS SANTOS e FRANCIONE DE PAULA ROCHA, que trazia consigo a pequena MANUELA de dois anos e meio, sua filha com RAFAEL. Em busca pessoal em RAFAEL e RUBEM nada foi encontrado, enquanto que FRANCIONE foi colocada de lado com a criança no colo, porém ao verificar o veículo TOWNER foram localizados dezenas de tabletes de substância assemelhada a maconha, sendo então imediatamente exarada voz de prisão aos mesmos pelo crime de tráfico de drogas, solicitado então o apoio de uma outra equipe desta unidade apenas para conduzir os veículos até esta delegacia. Relatou que ao ser questionado, RUBEM declarou nada saber sobre as drogas, alegando que estava apenas fazendo um frete/carreto e que não perguntou o que seria transportado, só percebendo do que se tratava quando viu RAFAEL pegar um dos invólucros, enquanto que RAFAEL ao ser questionado, afirmou que estaria intermediando a venda daquela droga e que ganharia o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para isso, que veio como batedor na frente do veículo com as drogas para ver se havia algum bloqueio policial no caminho, deixando a sua namorada e filha no veículo de RUBEM para despistar uma possível abordagem (...)".

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Fernando Antônio Brighenti Pereira na referida fase (fls. 11).

E, sob o crivo do contraditório (fls. 436/438), Eder confirmou, em síntese, seu depoimento inicial. Salientou que, ao verificar os entorpecentes, notou que um dos sacos de maconha já estava aberto. Citou que, no aparelho celular da ré, havia fotos das drogas apreendidas e de diversas outras. Mencionou que a informação obtida, acerca da negociação das drogas, não fazia menção a pessoas. Por fim, mencionou que não ouviu o relato da ré sobre o ocorrido.

Já Fernando, na fase judicial (fls. 436/438), também corroborou suas palavras iniciais. Destacou que Rubem, informalmente, declarou que receberia trezentos reais pelo frete. Asseverou que, no distrito policial, o delegado pediu autorização para vistoriar o celular de Francione e, na ocasião, foram vistos vários vídeos dela filmando drogas. Destacou que a informação, relativa à entrega das drogas, não fazia menção a pessoas. Esclareceu que a ré, após a visualização do celular, acabou admitindo que teria feito os vídeos a pedido de Rafael e imaginou que os teria apagado. Após a visualização dos vídeos, Rafael afirmou ser prática comum que pessoas, ao intencionar adquirir narcóticos, pedissem a filmagem destes previamente. A testemunha asseverou que Rafael não declarou pertencer a organizações criminosas. Por fim, o depoente não se recordou se Rafael fez menção ao tempo de dedicação à traficância.

Logo, cotejando-se tais elementos de prova, vê-se que bem delineada ficou a mercancia ilícita.

Nesse sentido, frise-se em resumo que, a par da prova documental e pericial da materialidade, os réus Rafael e Francione, na fase inquisitiva, confessaram integralmente a prática delitiva, ao passo que o corréu Rubem, na referida fase, também admitiu a participação no nefando comércio, declarando que, no curso da empreitada criminosa, percebeu que estava a transportar entorpecentes e, não obstante, continuou em tal atividade.

Os policiais civis, por sua vez, sempre que ouvidos, esclareceram que, após notícias acerca do transporte de elevada quantidade de drogas, vieram a surpreender os réus nas proximidades do veículo onde estas se encontravam. Na ocasião, segundo os agentes da lei, o réu Rafael confirmou que estava intermediando a venda dos narcóticos e que havia contratado Rubem para transportar tais substâncias. Rafael, ademais, ainda segundo os policiais, teria incumbido a ré Francione de acompanhar o transporte dos estupefacientes. Disseram os agentes da lei, outrossim, que Rubem admitiu que, durante a ação criminosa, chegou a perceber que estava a transportar entorpecentes.

E, sob o crivo do contraditório, os agentes da lei acrescentaram que, no aparelho celular da ré, foram avistadas várias imagens de diversas drogas. Na ocasião, segundo o policial Fernando, Francione declarou que havia feito os vídeos a pedido de Rafael. Já este, de acordo com Fernando, afirmou ser prática comum que pessoas, ao intencionar adquirir narcóticos, pedissem a filmagem destes previamente.

De outro turno, considerando-se a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (144 "tabletes" de maconha, com massa líquida de 83,6 quilogramas – fls. 56/58 e 71/73), bem se vê que outra não seria a finalidade destas se não a mercancia ilícita.

Bem delineada ficou, portanto, à vista de tais elementos, a prática da traficância por parte dos réus.

É de rigor, portanto, a condenação.

É caso, ainda, por expressa disposição legal, de declarar-se a perda, em favor da União, do veículo Asia Towner VBR, já que utilizado no transporte dos entorpecentes.

A combativa Defesa, porém, procura afastar o decreto condenatório.

Razão, entretanto, não possui a ilustrada Defesa.

Preambularmente, para que de pronto se afastem quaisquer questionamentos sobre a confiabilidade dos depoimentos prestados por policiais, agentes da lei, deve ser conferido o ensinamento doutrinário:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54). Assim, como já decidido, 'é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser analisado no contexto de um exame global do quadro probatório' (TACrimSP, RT 530/372)" (Damásio Evangelista de Jesus, "Código de Processo Penal Anotado", Editora Saraiva, 8ª edição, 1990, pág. 153).

Nesse entendimento, confira-se ainda o posicionamento jurisprudencial:

"PROVA - Testemunha - Depoimentos prestados por policiais - Decreto condenatório por uso de entorpecentes, baseado neste tipo de prova - Admissibilidade se inexistente qualquer indício de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo" (RT 765/584).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Presunção juris tantum de agirem escorreitamente no exercício da função" (RJTJSP 125/563).

No presente caso, não havendo provas de que os policiais fossem desafetos dos réus, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, deve ser recebido sem qualquer reserva o testemunho dos agentes da lei, inda mais porque corroborado pela apreensão de drogas e pela confissão dos réus Rafal e Francione na fase extrajudicial.

Na verdade, se afigura amplamente inverossímil que policiais, por mero capricho, percorram as vias desta comarca a incriminar falsamente desconhecidos, despendendo os notoriamente parcos salários com supostas aquisições de entorpecentes e com alegadas falsas apreensões de valores, alguns até excessivamente elevados.

É ilógica, destarte, qualquer ilação acerca de falsa incriminação dos policiais.

Lembre-se, outrossim, que dificilmente testemunhas civis, por medo de represálias, se prestam a comparecer à Delegacia de Polícia, razão pela qual não se pode exigir que a palavra dos policiais seja corroborada por pessoas estranhas aos quadros policiais.

Nessa esteira, vale conferir o entendimento jurisprudencial:

"...não se pode condenar a prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar circunstâncias da diligência. Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilidade de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até a calar ou negar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de

ser atingida" (TJSP - Rel. Des. Acácio Rebouças - RTJSP 13/478).

Sob outro aspecto, a ausência de filmagens e de fotos, relativamente à diligência que resultou na prisão dos réus, não chega a macular a prova.

Não se perca de mente, ainda, que é notória a precariedade dos meios de trabalho normalmente colocados à disposição dos policiais, não se podendo deles exigir que providenciem os equipamentos necessários para o exercício de seu mister.

Frise-se, sob outro ângulo, que a ré concorreu para a prática do crime, extraindo imagens das drogas para viabilizar a venda e, a fim de despistar a ação policial, acompanhando o transporte destas.

Assim, na forma do artigo 29 do Código Penal, a ré deve responder por sua reprovável conduta.

Sob outro prisma, a participação do réu Rubem no nefando comércio acabou bem delineada nos autos.

A respeito, sublinhe-se que é incontroverso, nos autos, que Rubem fora contratado para dirigir o veículo dentro do qual houve a apreensão dos entorpecentes, pois ele admitiu isso sempre que ouvido, ao passo que o corréu Rafael confirmou a contratação em ambas as fases da persecução penal. Já os policiais, nas duas oportunidades em que ouvidos, confirmaram que, informalmente, Rubem admitiu ter sido contratado, por Rafael, para o transporte.

O que se discute, então, é a ciência de Rubem no tocante ao que era transportado.

E aqui, respeitado o convencimento da Justiça Pública e da Defesa, há prova segura de que Rubem tinha consciência que estava a transportar narcóticos.

Nesse sentido, destaque-se que a negativa de Rubem é francamente inverossímil, não sendo crível, inicialmente, que alguém aceite realizar um frete sem saber o que está a transportar, inda mais quando não há a apresentação de qualquer nota fiscal e a contratação parte de alguém que, segundo o referido réu declarou na fase inquisitiva, era conhecido como usuário de drogas (fls. 18).

Tampouco se pode crer que Rubem não tenha acompanhado o carregamento de seu veículo, pois tal conduta é inusual.

Também não é admissível que, durante o percurso de entrega, Rubem não tenha percebido que transportava cento e quarenta e quatro "tabletes" de maconha, com massa líquida de 83,6 quilogramas (fls. 56/58 e 71/73).

As circunstâncias dos fatos, ademais, bem demonstram que Rubem tinha ciência do que estava a transportar estupefacientes, pois se dispôs a levar a carga para local desconhecido, acompanhado da ré, que carregava uma criança de colo.

E não é crível que Rafael corresse o risco de contratar alguém para o transporte de elevada quantidade de narcóticos sem que o contratado soubesse o que estava a fazer.

Não há dúvida, destarte, da ciência de Rubem acerca da participação na entrega dos estupefacientes.

Ainda que assim não fosse, lembre-se que Rubem, na fase inquisitiva, esclareceu que, após a primeira parada com o veículo, constatou que estava a transportar entorpecentes, mas ainda assim prosseguiu na ação, dirigindo o automóvel por orientação de "Branco", que seria o comprador das drogas (fls. 18), relato confirmado, sob o crivo do contraditório, pelos policiais.

Dessa forma, mesmo que não tivesse inicialmente ciência do que estava a ocorrer, Rubem acabou por aderir à conduta de transportar entorpecentes, devendo, então, por ela responder.

E aqui cabe salientar, em relação ao liame subjetivo entre os réus, que tal acordo de vontades prescinde de ser prévio à conduta criminosa, bastando apenas que o agente adira à ação do outro, objetivando, assim, a participação no crime, tal como aqui teria ocorrido.

Não há como, destarte, afastar-se o acolhimento integral da pretensão punitiva.

Procede-se, agora, à dosimetria das penas.

Atendendo-se às diretrizes estabelecidas pelos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, vê-se que a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal, não obstante a primariedade dos réus Francione e Rubem (fls. 98 e 101) e a primariedade técnica do réu Rafael (fls. 99/100).

A respeito, consigne-se que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 preceitua que, na fixação das penas, deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida com os réus.

E, no presente caso, elevada foi a quantidade de drogas apreendidas com os réus, chegando a mais de oitenta e três quilos de maconha.

Fixa-se a pena-base, assim, em seis anos de reclusão, além de seiscentos dias-multa (aumento de um quinto).

Não é caso, em seguida, de reconhecimento, como atenuante, da confissão, pois esta foi parcial, procurando Rafael e Francione, de forma reprovável, induzir o juízo a erro, negando a participação de Rubem.

Nesse mesmo sentir, sem embargo dos respeitáveis entendimentos em sentido contrário, confira-se a lição da jurisprudência:

“Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).

Não há circunstâncias agravantes a considerar.

Analisando-se, porém, as causas de diminuição e de aumento de pena, reconhece-se, quanto a Rubem, a de diminuição prescrita pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº

11.343/06.

Preceitua o citado dispositivo legal que, "Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

E, no presente caso, observa-se que Rubem é primário, tal como retro exposto, e não há prova de que integrasse organização criminosa ou que vinha dedicando-se a atividades criminosas além da ora apurada, tratando-se, ao que tudo indica, de mero motorista.

Deve-se reconhecer, dessarte, quanto a Rubem, a causa de diminuição prescrita pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no máximo previsto, ou seja, em dois terços, chegando-se a dois anos de reclusão, além de duzentos dias-multa.

E aqui cabe frisar que, respeitados os doutos entendimentos em sentido contrário, a quantidade dos entorpecentes, já que anteriormente analisada na primeira fase da dosagem da pena, não pode, sob pena de ocorrência do proscrito bis in idem, ser novamente considerada neste momento para a eleição da fração de redução.

A benesse ora examinada, entrementes, não se aplica aos réus Rafael e Francione.

Nesse trilhar, sublinhe-se não ser crível que os réus Rafael e Francione não se dedicassem a atividades delituosas, já que, pela quantidade e natureza dos estupefacientes – mais de oitenta e três quilos de maconha – certamente mantinham contatos com organizações criminosas, delas sendo pessoas de confiança.

Ainda que assim não fosse, lembre-se que Rafael, na fase inquisitiva, bem demonstrou que ele e Francione atuavam rotineiramente no nefando comércio.

Nesse sentido, declarou Rafael, referindo ao tráfico de drogas, que "...não possui passagem, mas que há algum tempo mexe com isso. Declarou que usa o telefone de FRANCIONE de vez em quando e que as fotos encontradas são suas e não dela, que ela sempre foi contra mexer com isso, mas que o ajuda por amor, para ajudar a família (...) Por fim declarou que apenas intermédia as negociações de drogas, mas que não tem acesso a fonte das mesmas" (fls. 21).

Já Francione, na fase policial, declarou que "...sempre soube que RAFAEL tinha envolvimento com o tráfico de drogas" (fls. 16).

Lembre-se, outrossim, que os policiais, sob o pálio do contraditório, confirmaram que, no aparelho celular de Francione foram encontrados imagens de variados entorpecentes, ao passo que o agente da lei Fernando, na referida fase, confirmou que Francione admitiu que gravava vídeos de narcóticos a pedido de Rafael. Já este, segundo Fernando, declarou que era costumeiro compradores de entorpecentes solicitarem tais vídeos.

A dedicação de Rafael e Francione às atividades criminosas, portanto, é patente.

Afasta-se, destarte, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, a incidência da referida causa de diminuição quanto aos citados réus.

O valor do dia-multa, à vista da precária situação financeira dos réus (fls. 17, 31 e 40), é fixado no mínimo legal.

As penas, a seguir, são tornadas definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, adota-se, quanto a Rubem, o aberto, nos termos do determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603-SP.

Em seguida, ainda nos termos do preceituado pelo mencionado writ, é caso de reconhecer-se que Rubem preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal.

Nesse sentido, veja-se que a pena privativa de liberdade é inferior a quatro anos e o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Rubem, ademais, é primário.

Opta-se, entretanto, pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, § 2º, do Código Penal), pois somente a aplicação de pena de multa, ainda que cumulada com outra vicariante, não se revelaria uma resposta penal compatível à grave conduta apurada nos autos.

Resta analisar quais das penas elencadas no artigo 43 do Código Penal são as mais adequadas a Rubem, sendo capazes de evitar o cometimento de novos delitos e de propiciar-lhe novos conceitos e uma oportunidade de realizar atividades em prol da comunidade, revertendo, em frutos de labor, o dano em potencial causado no seio desta.

Por conseguinte, observar-se-á, na substituição, a interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares e a prestação de serviços à comunidade (artigo 43, incisos IV e V, do Código Penal).

Caso não prevaleça a substituição, o regime prisional a ser observado, como já dito, será o aberto.

Sublinhe-se, outrossim, que o período da prisão cautelar não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que já se adotou, in casu, o mais brando deles quanto a Rubem.

Em relação a Rafael e a Francione, à vista da gravidade dos fatos, do risco que o tráfico de entorpecentes representa à sociedade, destruindo famílias, pessoas, projetos e a própria comunidade, não há como aplicar-se ao caso outro regime que não o fechado.

E não se diga que é inconstitucional a eleição de regime prisional mais severo nos chamados crimes hediondos e equiparados, já que se trata de critério legislativo, a espelhar a vontade da população, que espera ver mais severamente apenados tais espécies de delitos, os quais, ademais, afetam gravemente a ordem pública.

A pena privativa de liberdade relativa a Rafael e Francione, assim, será cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos da Lei nº 8.072/90.

Sublinhe-se, outrossim, que o período da prisão cautelar não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que não há nos autos qualquer informação sobre o comportamento carcerário dos mencionados réus.

O citado lapso temporal, ademais, seria inábil para permitir qualquer progressão.

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

a) CONDENAR-SE FRANCIONE DE PAULA ROCHA e RAFAEL NIVALDO DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, nos termos da Lei nº 8.072/90, a pena de seis anos de reclusão, bem como a recolher seiscentos dias-multa, fixada a diária no mínimo legal;

b) CONDENAR-SE RUBEM ALOÍSIO DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de dois anos de reclusão, bem como a recolher duzentos dias-multa, fixada a diária no mínimo legal;

c) SUBSTITUIR-SE a pena privativa de liberdade aplicada ao réu Rubem pelas seguintes vicariantes:

c.1) interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequência a locais de reputação duvidosa, tais como bailes, "baladas", bares, "biqueiras", botecos, danceterias, discotecas, forrós, "pancadões" e zonas de meretrício, com recolhimento à residência, diariamente, entre 22h00 e 05h00, salvo em emergências médicas e compromissos profissionais;

c.2) prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Egrégio Juízo da Execução;

d) CONDENAR-SE FRANCIONE DE PAULA ROCHA, RUBEM ALOÍSIO DOS SANTOS e RAFAEL NIVALDO DA SILVA, ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Paulista nº 11.608/03);

e) DECLARAR-SE A PERDA, em favor da União, do veículo ASIA TOWNER VBR, de placas CHP 2050 (fls. 57).

Para eventual concessão da gratuidade judiciária, deverá a ilustrada Defesa apresentar declaração de pobreza, assinada pelos réus sob as penas da lei (fls. 377, in fine).

O réu Rubem, beneficiado que foi, nesta instância, com penas vicariantes e, alternativamente, com regime, poderá apelar em liberdade.

A ré Francione, da mesma forma, poderá recorrer sem recolher-se à cadeia, já que agraciada, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a prisão domiciliar (fls. 280/291).

Por estarem presentes, nos autos, os requisitos da custódia cautelar, o réu Rafael respondeu preso ao processo, razão maior havendo, agora condenado, para permanecer sob a custódia do Estado, a fim de garantir-se a saúde e a ordem públicas, pois estas podem ser seriamente abaladas com o tráfico de entorpecentes.

Recomende-se o réu Rafael, portanto, na prisão em que se encontra.

Solicite-se a destruição da substância entorpecente, requisitando o posterior envio, a este juízo, do laudo respectivo, devendo ser mantida quantidade suficiente para contraprova até o final do processo.

Com o trânsito em julgado, determinar-se-ão as devidas anotações e comunicações.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 06 de dezembro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA  
FOL/ESC